

1544190-10.2018.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Leve

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito do artigo 28 da referida Lei, com consequente remessa dos autos ao JECRIM.

Requeru, ainda, a absolvição sumária em relação aos delitos da Lei nº 10.826/03 e a realização de diligências.

Por r. decisão exarada às fls. 227/229, foram indeferidos os pedidos formulados pela i. defesa, sendo recebida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1544190-10.2018.8.26.0562 - Controle 2018/001003

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Leve

Documento de Origem:

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILSON RODRIGUES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

NILSON RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 16, parágrafo único, inciso IV e 12, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), e do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, todos combinados entre si na forma do concurso material (artigo 69 do Código Penal), porque, no dia 04 de dezembro de 2018, na Rua Um, nº10, Vila Progresso, em Santos, o acusado possuía um revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, nove cartuchos e três estojos, todos de munições calibre 38, de uso permitido. Ele agia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, na denúncia, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o acusado guardava e tinha em depósito um tijolo de maconha com peso aproximado de 70 gramas, além de um cigarro da mesma droga, capaz de causar dependência física. O acusado pretendia vender tudo no comércio clandestino. Ele agia sem qualquer tipo de autorização.

O auto exibição e apreensão encontra-se acostado às fls. 12/13.

O laudo pericial dos objetos apreendidos encontra-se encartado às fls. 44/46.

Às fls. 66/69, encontra-se acostado o laudo da perícia realizada na arma e munições apreendidos, o qual foi complementado pelo laudo de fls. 259/261.

O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 96/98.

A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 117/125.

Por r. decisão exarada às fls. 126/127, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. Na oportunidade, foi determinado o arquivamento do feito em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça, com ressalvas do artigo 18 do C.P.P.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se encartado às fls. 144/146, tendo resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (THC).

O acusado foi pessoalmente notificado às fls. 194 e 196.

A i. defesa do acusado apresentou defesa preliminar às fls. 197/216, requerendo a remessa dos autos ao i. Promotor de Justiça para oferecimento de proposta de não persecução penal, a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito do artigo 28 da referida Lei, com consequente remessa dos autos ao JECRIM. Requereu, ainda, a absolvição sumária em relação aos delitos da Lei nº 10.826/03 e a realização de diligências.

Por r. decisão exarada às fls. 227/229, foram indeferidos os pedidos formulados pela i. defesa, sendo recebida a denúncia.

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 263/264.

Por r. decisão exarada às fls. 265/266, foi indeferido o pedido formulado pela i. defesa, no sentido de serem os autos remetidos ao Procurador Geral de Justiça de São Paulo.

Em audiência virtual realizada no dia 23 de agosto de 2021, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foi ouvida uma testemunha de acusação, sendo o réu interrogado. Em deliberação, foi deferido o pedido formulado pela i. defesa e determinada a instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 317/318).

O laudo pericial foi acostado às fls. 74/81 dos autos em apenso, tendo os experts do Juízo concluído que, sob a ótica medico-legal, o acusado é imputável.

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a improcedência da ação penal, em relação aos delitos descritos nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV e 12, caput, ambos da Lei nº 10.823/06, uma vez que, durante a instrução processual, não restou demonstrada a prática dos delitos. No que tange ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes descrito na denúncia, requereu a desclassificação para o delito do artigo 28 da referida Lei, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 332/334).

A ilustre defesa do réu manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a improcedência da ação penal, com a absolvição do réu, em virtude da insuficiência probatória (fls. 338/342).

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, posto que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, não havendo provas que apontem a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como a prática dos crimes descritos no artigo 16, parágrafo único, inc. IV e artigo 12, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, como o descrito na denúncia.

A materialidade do delito de posse de drogas para consumo pessoal restou devidamente demonstrada, pela portaria de fls. 02/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelo relatório final de fls. 96/98, bem como pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 144/146, atestando resultado positivo para a substância Tetrahydrocannabinol (THC).

Por sua vez, a autoria do delito restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante da prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, bem como diante da confissão do réu.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática dos delitos descritos no estatuto do desarmamento, alegando que reside ao lado de uma área de tráfico de drogas, e os garotos costumam adentrar em seu terreno. Um dia, ao chegar em sua residência, havia uma sacola contendo um revólver quebrado e decidiu guardar a sacola, a fim de verificar quem seria o dono, pois reside lá há mais de trinta anos. Afirmou que a arma não estava em condições de ser utilizada e nunca a usou, desde que foi encontrada. Quanto às drogas encontradas em sua residência, afirmou que se tratava de uma quantia aproximada de cinquenta gramas, utilizada para consumo próprio, pois é usuário de maconha. Em relação às anotações encontradas, esclareceu que são relativas a venda de um terreno em uma área de avanço, em terreno geminado. Finalmente, afirmou que a pequena balança encontrada em sua residência era utilizada por sua ex-esposa.

O policial civil Thiago Mendes de Oliveira, testemunha de acusação ouvida em Juízo, relatou que, alguns dias antes da data dos fatos, a vítima esteve na delegacia de polícia para elaboração de um boletim de ocorrência a respeito de violência doméstica, tendo como autor o réu, que seria convivente dela. A vítima mencionou que o réu possuía uma arma em sua residência. A delegada de polícia representou pela expedição de mandado de busca e, em cumprimento ao mandado de busca, foram encontrados os objetos e a arma descritos na denúncia. Esclareceu que o réu não estava presente, e não havia ninguém que pudesse acompanhar a diligência. Relatou que o local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão é muito próximo a um ponto de tráfico de drogas, onde os traficantes permanecem armados o dia todo. Relatou, ainda, o depoente, que dentro de uma gaveta, em uma cômoda, foi localizada uma arma com cinco munições intactas, e junto dela havia mais quatro munições intactas, e três estojos já deflagrados. Em cima de uma mesa havia um cigarro de maconha, com peso aproximado entre 60 e 70 gramas, suficientes para a confecção de alguns cigarros e alguns fragmentos de entorpecentes. Foram também encontrados uma caderneta com anotações de valores, uma balança de precisão e material para a confecção de cigarro artesanal. Os objetos foram todos apreendidos e levados à delegacia de polícia. Afirmou que não conhece o réu.

O depoimento do policial, seja ele militar ou civil, desde que prestado de forma condizente, é idôneo e goza de presunção de veracidade, sendo analisado em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação”. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Ressalte-se que, segundo o depoimento prestado pelo policial civil ouvido em Juízo, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, o mesmo não estava presente e não havia qualquer pessoa que pudesse acompanhar a diligência. E, ainda, nenhum ato de traficância foi por ele presenciado, uma vez que a testemunha não conhece o réu e não manteve contato com ele.

A prática dos delitos descritos na denúncia não foi comprovada pelas provas colhidas em Juízo.

Como se verifica do depoimento prestado pelo policial civil, não restou comprovado que o acusado tenha praticado comércio ilícito de entorpecentes, pois nenhum ato de traficância foi presenciado.

A versão do acusado, no sentido de ter adquirido entorpecentes para consumo pessoal

é crível, e não pode ser descartada.

A prova produzida no curso da instrução processual aponta, inquestionavelmente, apenas para a prática do crime de porte de substância entorpecente para uso pessoal, merecendo acolhida a tese ministerial no tocante à desclassificação do delito descrito no artigo 33 da Lei de Drogas para o artigo 28 da mesma lei. Instaurado incidente de dependência toxicológica, nos autos em apenso, os peritos do Juízo concluíram ser o réu imputável.

No que tange à prática dos delitos descritos no artigo 16, parágrafo único, inc. IV e artigo 12, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, esta também não restou demonstrada. O laudo pericial de fls. 66/69 concluiu que a arma encontrada na residência do réu, no estado em que se encontrava, não estava apta para a realização de disparos, uma vez que o mecanismo de disparo estava danificado, retém do tambor estava ausente, cão e gatilho estavam travados.

O crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 tem como bem jurídico tutelado a segurança coletiva, direito fundamental previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal.

No presente caso, não houve nenhuma ofensividade ao bem jurídico tutelado, posto que não há potencial lesivo na arma de fogo apreendida na residência do réu, estando a arma inapta a efetuar disparos, conforme o laudo de fls. 66/69.

Restou amplamente caracterizada a falta de ofensividade ao bem jurídico tutelado, não pairando quaisquer dúvidas acerca da ausência do potencial lesivo da arma de fogo, diante da sua inaptidão para efetuar disparos, tornando-se uma conduta totalmente atípica.

O princípio da ofensividade está encartado na ideia de “lesividade”, e pode ser expresso, sinteticamente, pela ideia de que não existe delito sem lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico protegido. Tal princípio vem ganhando protagonismo nos últimos anos e é um dos fundamentos do Direito Penal Moderno. Não basta que o comportamento do agente esteja adequado aos requisitos estruturais do tipo (verbos e requisitos normativos) se não for possível identificar no objeto material da conduta uma efetiva “potencialidade lesiva”.

De tal sorte, torna-se necessário constatar, no caso concreto, se a arma estava apta a ser utilizada, sendo idônea para causar danos ou expor a perigos o bem jurídico protegido pela norma.

Se a arma não estiver apta ao seu uso natural (realização de disparos) não possuindo, portanto, danosidade, estará ausente a ofensividade e não ocorrerá o delito.

Nesse sentido:

"Porte de arma de uso restrito. Artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. Pretendida absolvição. Admissibilidade. Arma inapta a efetuar disparos, com anomalias em seu sistema. Absoluta ineficácia do meio. Bem jurídico que não se encontra em risco. Crime impossível. Absolvição decreta com fulcro no art. 386, III, do C.P.P. Apelo defensivo provido. (TJ - SP APL: 00081598720148260309 SP 0008159-87.2014.8.26.0309, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 14/04/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2015)."

Da mesma, o laudo pericial acostado às fls. 259/261, complementar ao laudo de fls. 66/69, concluiu pela impossibilidade técnica do Instituto de Criminalística em aferir ou não a eficácia e a aptidão das munições apreendidas na residência do acusado, uma vez que não fora realizado teste de eficiência nas munições apreendidas, diante do fato de que a arma encaminhada para exame, juntamente com as munições, não poderia ser utilizada para realização de disparos. Salientou, ainda, o Sr. Perito, que aquele instituto não possui estrutura apropriada para realização de teste de eficiência de munições.

Diante dos laudos acostados, não há prova, também, da tipicidade do delito descrito no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 imputado ao réu na denúncia.

Assim, com relação aos delitos do artigo 16, parágrafo único, inc. IV e artigo 12, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, descritos na denúncia, impõe-se o decreto de absolvição do acusado, por ausência de prova da materialidade, tornando-se fatos atípicos.

Assim sendo, considerando a prova produzida em Juízo, impõe-se o desfecho de procedência parcial da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra NILSON RODRIGUES DA SILVA, a fim de ABSOLVE-LO das imputações contidas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV e artigo 12, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e a fim de DESCLASSIFICAR o delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para condena-lo como incurso nas penas do artigo 28 da referida Lei.

O acusado é primário e, de acordo com os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, observando-se o disposto nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 28 do mencionado diploma legal.

Torno definitiva a pena aplicada.

Ora fixada a pena em concreto, em 03 (três) meses de reclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06, "prescrevem em 02 anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal".

Os fatos ocorreram no dia 04 de dezembro de 2018, sendo a denúncia recebida em 10 de novembro de 2020 (fls. 227/229).

Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, decorreu prazo superior a dois anos, sem que houvesse causa interruptiva da prescrição.

Desta maneira, observando-se os elementos em tela, ocorreu no presente caso a chamada prescrição da pretensão punitiva, causa esta de extinção da punibilidade.

Assim sendo e diante da manifestação do i. representante do Ministério Público, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NILSON RODRIGUES DA SILVA, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 30 da Lei nº 11.343/06.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

P.I.C.

Santos, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA